

人名下的方式，骗取某保险公司上海分公司支付的新人训练津贴、增员奖等额外奖励。这恰恰是利用自己作为业务主任、业务总监等职务便利，向保险公司隐瞒真实的情况，虚构自己邀请并负责管理的下级保险代理人的业务情况。

综上，被告人徐某某、朱某某伙同他人，利用被害单位公司工作人员具有职务上的便利，将被害单位的财物占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人徐某某、朱某某还违反国家有关规定，单独或共同以其他方法非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予二罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，法院予以支持。在职务侵占的共同犯罪中，被告人徐某某、朱某某起主要作用，系主犯；被告人朱某某到案后如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论，依法可以减轻处罚；被告人徐某某、朱某某当庭能如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。二名被告人已退赔全部违法所得，亦可以酌情从轻处罚。

据此，上海市静安区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二百七十一条第一款，第二百五十三条之一第一款、第三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第二款，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人徐某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币15万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币6万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币21万元；

二、被告人朱某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币15万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币20万元；

三、退赔的违法所得发还被害单位某保险公司上海分公司。
案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

职务侵占罪的主体是公司、企业或其他单位的工作人员，学理上一般认为这既包括与单位缔结劳动关系的员工，也包括与单位仅存在劳务关系的人员。

保险代理人与保险公司之间,由于双方签订保险代理合同,在民事法律关系上属于委托代理的法律关系,有别于一般认知当中的公司工作人员即正式工、合同工、临时工。但刑事法律关系不同于民事法律关系侧重形式要件,更应当根据实质的工作内容、职责范围、监督管理等进行判断。由此可以判断出,在实质上保险代理人与保险公司的内部工作人员无异,可以视为保险公司的工作人员,成为职务侵占罪的主体。

一、保险代理人与保险公司存在事实劳动关系

由于一个单位存在的主要目的或意义,并不在于集中区分、赋予公民各自的社会角色或身份,而在于组织、分配一定的社会职责或业务活动^①,因此判断保险代理人与保险公司之间的关系,不应囿于双方签订的保险代理合同,或是保险代理人是否存在“编制”,而是应探究保险代理人在保险公司处履行的实质职责与业务方式。职务侵占罪的一个重要的特征是“因职而占”,更重要的是强调行为人在侵占公司财物时有没有利用职务上的便利,必须考虑他是否拥有了一定的职务或承担相应职责,而对于其是否是在编人员,并没有实际的刑法意义。^②

根据《中华人民共和国保险法》第一百二十五条规定,个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时,不得同时接受两个以上保险人的委托。《保险代理人监管规定》第三十八条第二款明确规定,个人保险代理人、保险代理机构从业人员只限于通过一家机构进行执业登记,故保险代理人同一时期,仅能为一家保险公司工作。实践上,虽然保险代理人的流动性高于其他行业,但基本上保险代理人仍会较为稳定地为同一家保险公司工作一段时间。与之相关的,保险公司设立新人训练津贴的初衷,就是通过一年时间的额外补贴,留住保险代理人为本公司服务,以提高人员稳定性,确保业务质量。可见保险公司不是将保险代理人视为简单的委托代理关系,而是公司所雇佣的工作人员。

保险代理人入职保险公司时,保险公司也为保险代理人提供培训,教授相

①黄祥青:《职务侵占罪的立法分析与司法认定》,载《法学评论》2005年第1期。

②马松建:《侵占罪专题整理》,中国人民公安大学出版社2007年版,第436~438页。

关法律法规,以及内部规章制度设立的奖惩机制。相关内容不存在于保险代理合同中,而是独立于委托代理关系外,更接近于公司内部员工手册。保险代理人展业时,对外以保险公司的名义,需要登录保险公司的办公系统登记信息,受保险公司内部监督员监督管理。保险代理人根据工作业绩提取佣金,工作业绩未达标可能导致无法取得佣金。

据此,保险代理人一定时间内为一家保险公司工作,接受保险公司的指导和培训,遵守保险公司的内部规章制度,并由此收取佣金。保险公司对于保险代理人的业务管理与指导构成了管理与被管理的隶属关系。从委托人的局限性、被委托人的约束性、委托费用的不对等性等多个方面看,双方之间的委托代理关系已经偏离了一般民事委托代理的范畴。保险代理人长期持续、反复地履行保险公司规定的职责、从事保险公司经营的保险业务,名为委托代理关系、实为事实劳动关系,在实质上就属于保险公司工作人员。

二、保险代理人具有职务上的便利条件

从刑法上看,凡是规定利用职务上的便利实施的犯罪,无不对其主体予以明确规定。刑法上对上述犯罪明确规定主体的依据在于明确体现该罪的构成特征,这同时为界定“利用职务的便利”的含义提供了法律依据。^①保险代理人是否在保险公司的业务经营范围内取得职务便利成为保险代理人是否能够成为职务侵占罪主体的关键。

在学理上,一直强调“利用职务的便利”与“利用工作的便利”的区分。仅仅因为工作内容的原因接触到相关的财物本身,并不能作为职务侵占罪的前提条件。“利用职务便利”即是利用自己主管、管理、经营单位财务的便利条件,但对“主管”“管理”“经营”应是指对单位财务的控制和支配,而非普通意义上的经手。^②保险代理人在展业过程中,对于经手的业务具有一定的管理权。保险代理人以保险公司的名义与投保人洽谈保险业务的过程,其实并不为保险公司所知。保险公司仅能根据签订后的保险合同内容进行审查,详细的

^①刘志伟:《职务侵占罪的理论及司法适用》,中国检察出版社2000年版,第153页。

^②张明楷:《刑法学(下)》,法律出版社2016版,第1021页。

协商过程中，双方是否有所隐瞒抑或恶意串通，并不会被保险代理人与投保人以外的第三人所确认。此过程中，保险代理人享有的即是保险公司因业务范围赋予经营管理的职务便利。

《中华人民共和国刑法》第一百八十三条第一款规定，保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚（职务侵占罪）。

《中华人民共和国刑法》已经为保险公司的工作人员在展业过程中，对经手保险业务具有一定管理职责进行背书。前文已经论述，保险代理人在实质上与保险公司内部的工作人员无异，那么同理，保险代理人在上述情形下，同样因具有职务上的便利，被认定为职务侵占罪。

除保险代理人与投保人恶意串通，编造虚假的保险事故骗取保险金能够体现保险代理人对于保险业务经营的职务便利外，保险代理人在工作过程中，还具有推荐新人以及上下级管理的人事职责。保险代理人的组织结构相较于一般公司更为松散，以老带新、家族内部相互推荐的入职模式更为普遍，由此反而形成信息茧房，保险公司对此难以掌控，只能借助保险代理人的内部管理。

保险公司设立新人激励机制是为了留存有业务资源的保险代理人，给到保险代理人一定的推荐费用及新人补贴。保险代理人却利用保险公司赋予的人事职责，用以虚构新人的情况，以虚假信息换取保险公司额外的佣金。在权利外观上，这只是保险代理人一种取得佣金的权利，但该权利具有相应的义务，就是为保险公司的保险代理人队伍发展提供一定的帮助。而将真实的业务挂在虚假的新人名下，不仅对于保险公司发展队伍没有帮助，还损害保险公司的实际经济利益。因此，相关人事职责也应视为保险代理人在职务上的便利。

编写人：上海市静安区人民法院 顾正仰 周子扬

职务侵占罪中“公司、企业或者其他单位的工作人员” 及“非法占为己有”的认定

——顾某某等职务侵占案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省苏州市中级人民法院(2023)苏05刑终176号刑事裁定书

2. 案由：职务侵占罪

【基本案情】

甲公司与被告人顾某某、被告人张某某签订劳动合同后，将二人派遣至同一集团公司下属的乙公司开发的某房产项目营销中心工作，由顾某某担任营销中心经理，负责参与制定销售方针政策、管理营销中心员工等，张某某担任营销中心销售主管，负责房产销售等。2019年5月，顾某某与从事房产中介的被告人顾某1商定，如有自行到访的购房者需要操作成中介带看的，由顾某1操作，顾某1可从乙公司支付的佣金中抽取10%左右的“好处费”。同年5月底6月初，顾某某、张某某在向自行到访客户沈某销售房产的过程中，私自商定将沈某的到访渠道由自行到访变更为中介带看，并打算后期将乙公司支付给中介顾某1佣金的一部分返还客户沈某作为购房优惠。后顾某某、张某某、顾某1共同伪造了沈某的中介带看资料，乙公司遂向合作的分销平台公司支付佣金287668.65元，平台公司扣除费用后向房产中介顾某1支付210957元，顾某1将其中180000元转给张某某、顾某某。2020年9月1日，被告人顾某某、张某某自动投案；后被告人顾某1被抓获归案。案发后，顾某某、张某某、顾某1

赔偿被害单位287669元。

【案件焦点】

1. 职务侵占罪中“公司、企业或者其他单位的工作人员”是否限于签订劳动合同的单位；2. 职务侵占罪的“非法占为己有”是否包括使第三人所有的情形。

【法院裁判要旨】

江苏省苏州市吴江区人民法院经审理认为：顾某某、张某某、顾某1共同利用顾某某、张某某的职务便利，将涉案公司财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。顾某某、张某某、顾某1的行为虽发生在《中华人民共和国刑法修正案(十一)》施行前，但根据从旧兼从轻原则，应适用修正后的《中华人民共和国刑法》第二百七十一条对其定罪量刑。在共同犯罪中，顾某某、张某某均系主犯；顾某1系从犯，依法从轻处罚。被告人顾某某、张某某均系自首，顾某1如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人顾某某、张某某认罪认罚，依法从宽处理。被告人顾某某、张某某、顾某1退赔了被害单位的损失，酌情从轻处罚。根据被告人顾某某、张某某、顾某1的犯罪事实、情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法均可以宣告缓刑。据此，对被告人顾某某、张某某依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人顾某1依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条之规定，作出如下判决：

一、被告人顾某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币35000元；

二、被告人张某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处

罚金人民币25000元；

三、被告人顾某1犯职务侵占罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币1万元。

一审宣判后，顾某某、张某某、顾某1均提出上诉。

江苏省苏州市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是售楼处工作人员与房产中介通谋，通过违规变更客户到访渠道的方式，获取房产公司付给中介的佣金的典型案例。此类行为是否构成职务侵占犯罪，应从该罪的立法目的和实践需要出发，准确审查界定。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定的职务侵占行为是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为。根据全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著的《中华人民共和国刑法解读》^①，构成本罪必须符合以下三个条件：（1）主体是公司、企业或者其他单位的人员；（2）行为人必须具有侵占本单位财物的行为；（3）行为人在主观方面是故意的，犯罪目的是非法占有本单位的财产。

一、“公司、企业或者其他单位的工作人员”主体要件的理解

本案审理过程中，一种观点认为，顾某某、张某某是和甲公司签订的劳动合同，并未与乙公司签订劳动合同，故不属于乙公司的工作人员，不符合职务侵占罪的主体要件；另一种观点认为，是否属于某个单位的“工作人员”，不应仅从劳动合同层面进行形式审查，还应综合行为人的身份、职权进行实质判断。

笔者同意第二种观点，理由如下：职务侵占罪的立法原意是通过惩处单位内部人员实施侵占单位财产的行为，从而保护单位财产。实践中，普遍存在关

^①全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著：《中华人民共和国刑法解读》，中国法制出版社2015年版。

联公司混同用工以及劳务派遣、劳务外包等灵活用工形态，对于劳动者在被派遣至其他公司从事劳务的过程中，利用职务便利，非法占有公司财物的行为，如以未签订劳动合同为由认为其不构成犯罪则会放纵犯罪，不利于单位财产保护；如否定其单位工作人员的身份而认定构成盗窃罪、诈骗罪之类，则完全忽略了利用职务便利的行为方式，也可能导致量刑失衡。因此，职务侵占罪中，行为人的单位不应机械理解为行为人劳动合同签订单位，还应包括行为人实际行使职权的单位。本案中，顾某某、张某某虽是与甲公司签订的劳动合同，却被安排至乙公司某房产项目售楼处担任营销经理、销售主管职务，负责销售房产等；对于中介带看的购房客户，二人也有申请乙公司向中介机构支付分销佣金的职权。顾某某、张某某实际在乙公司行使售房、申请支付分销佣金等职权，且依规行使职权的后果由乙公司认可并承担。因此，应当认定顾某某、张某某是被害单位乙公司的工作人员，二人通过变更客户到访渠道的方法使得乙公司向中介方支付佣金的行为也属于职务行为，而非个人行为，符合职务侵占罪的主体身份要件。

二、“非法占为己有”主观方面及客观行为的认定

顾某某、张某某最开始变更客户沈某到访渠道的目的是促成交易：从公司获取分销佣金，拿出部分返还给沈某作为购房优惠。后因在沈某认购房产后、付清房款前，公司出台新的优惠政策，沈某得以直接享受14万元左右的房款优惠，故顾某某、张某某后续未将佣金返还沈某。

笔者认为，顾某某等人从一开始即具有非法占有的主观故意。理由如下：职务侵占罪的立法目的是保护公司、企业或者其他单位的财产所有权。该罪的核心是惩处单位内部人员侵占单位财产，损害单位利益的行为，即追究的主要是侵占行为，而非被侵占财产去向。实践中，被侵占的单位财产可能由行为人自己占有，也可能由行为人指定其他人占有。如果对于员工利用职务之便，将单位财产私自处分给朋友、合伙人、其他利害关系人的情形排除在职务侵占行为之外，势必成为单位财产权益保护的巨大漏洞。因此，从立法目的及实践需要从两个方面看，该罪法条表述的“非法占为己有”，其界定不应限于行为人

自己所有，还应包括使第三人所有的情形。主观故意方面，只要行为人明知自己的职务行为会侵害本单位的财产权益即可，至于财产最后由谁非法占有不影响罪过；客观行为方面，只要是行为人通过自己的职务行为，使得本单位的财产被永久性地剥夺，就符合职务侵占罪的本质特征。本案中，顾某某、张某某、顾某1在最开始预谋将沈某的到访渠道由自行到访变更为中介带看之时，三人就知道他们的行为会导致乙公司额外支出一笔佣金，仍然在未征得乙公司同意的情况下，故意用隐瞒、欺骗的手段使乙公司丧失对涉案28万余元佣金的所有权，无论该笔款项他们是为了自己占有、与客户共同占有抑或全部给客户占有，均属于职务侵占行为。

综上分析，顾某某、张某某、顾某1的行为符合职务侵占罪的主客观构成要件，一、二审法院据此作出上述裁决。

编写人：江苏省苏州市吴江区人民法院 沈黎红 任远航

68

公司员工与外部人员合作设立公司并以高对价获取公司业务后 将业务通过虚设交易环节交给外部人员所任职公司 实施并获取差价及返点的行为应认定为职务侵占

——王某某、陈某某职务侵占案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2022)闽05刑终1428号刑事判决书

2. 案由：职务侵占罪

【基本案情】

自2013年以来，被告人王某某在广告公司(国有上市公司“某集团”的全资子公司)担任客户群总监、副总经理期间，与某食品公司网络推广部经理 被告人陈某某因广告业务建立合作关系。2014年11月7日，被告人王某某、陈某某及广告公司员工吴某某(另案处理)在某文化传媒公司，由被告人陈某某的表妹林某某担任法人代表、代持股份，实际由被告人王某某、陈某某分别持45%的股份、吴某某持10%的股份。2014年12月至2016年上半年，被告人 陈某某代表某食品公司与某文化传媒公司股东被告人王某某等人洽谈，并签订 四份广告代理合同，其中，“某食品广告投放合同”，合同标的310万元(币种 人民币，下同)，约定返点15万元，实际执行标的295万元；“某饮料广告投放合同”，合同标的200万元及200万元的等价商品投放；“某饮料广告投放合同”，合同标的500万元，约定返点30万元，实际执行标的470万元。同时，被告人王某某找到广州市某广告有限公司(以下简称某广告公司)，让某广告公司在名义上代理某食品公司的上述广告，以“过单”的形式承包给广告公司，由被告人王某某代表广告公司进行具体接洽、约定返点比例，某广告公司则从中赚取3%左右的过单费，并在收到广告公司的返点后把钱款转给某文化传媒公司。其中，被告人王某某将上述实际执行标的为295万元的“某食品广告投放合同”，标的为200万元及200万元等价商品投放的“某饮料广告投放合同”，合并为合同标的为430万元的“某集团2016年1月至4月网站投放广告 代理合同”，从中赚取差价65万元和返点115.4万元，从实际执行标的为470 万元的“某饮料广告投放合同”中赚取返点99.3万元，合计279.7万元。后被告人陈某某分别于2016年11月、2017年3月、2017年5月收到现金分红10万元、20万元、20万元，合计50万元。2020年4月9日，被告人王某某在某酒店被公安机关抓获。2020年5月18日，被告人陈某某到公安机关投案。案发后，被告人王某某、陈某某及苏某分别向公安机关退出赃款100万元、50万元、10万元。

【案件焦点】

公司员工与外部人员合作设立公司并以高对价获取公司业务后将业务通过虚设交易环节交给外部人员所任职公司实施并获取差价及返点的行为应如何认定。

【法院裁判要旨】

福建省晋江市人民法院经审理认为：被告人陈某某身为公司的工作人员，伙同被告人王某某，利用被告人陈某某职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额巨大，二被告人的行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某某归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人王某某、陈某某均退出部分赃款，予以酌情从轻处罚。鉴于本案审理期间，新公布并已施行的刑法修正案对本罪的量刑档次、幅度进行了调整，其中数额巨大的主刑幅度比原刑法条文的规定较轻，故本案依法应适用新的规定，据此，以职务侵占罪，判处被告人王某某有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20万元，判处被告人陈某某有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币15万元；暂扣在案的赃款人民币1600000元，由扣押机关予以发还被害单位某食品公司；责令被告人王某某、陈某某继续共同退赔被害单位某食品公司经济损失人民币1197000元。

一审宣判后，王某某、陈某某提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：陈某某身为公司的工作人员，伙同王某某，利用陈某某职务上的便利，共同将本公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。王某某归案后如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。陈某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。王某某、陈某某案发后能退出部分赃款，予以酌情从轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但对苏某退出的受贿款10万元处理不当，依法予以纠正。二审审理期间，陈某某家属代其退赔被害人部分经济损失并取得谅解，可再予以从轻处罚。据此，判决如下：

一、驳回上诉人王某某的上诉请求，维持福建省晋江市人民法院(2021)闽0582刑初2404号刑事判决第一项，即上诉人王某某的定罪量刑部分；

二、撤销福建省晋江市人民法院(2021)闽0582刑初2404号刑事判决第二项中上诉人陈某某的量刑部分及第三项、第四项涉案财物处置；

三、上诉人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15万元；

四、上诉人王某某、陈某某退出的暂扣于晋江市公安局的赃款人民币1500000元，返还被害单位某食品公司；苏某扣押于晋江市公安局的赃款人民币100000元予以没收，上缴国库；

五、责令被告人王某某、陈某某继续共同退赔被害单位某食品公司经济损失人民币1047000元。

【法官后语】

公司员工与外部人员为获取公司员工所任职公司的业务而合作成立新公司，且公司员工未实际出资，后利用公司员工的职务便利将公司业务高对价提供给所成立的公司，后该公司并未实际从事相关业务，而是将获取的业务通过几个中间交易环节转手提供给外部人员所任职的公司，从中赚取差价及返点，后外部人员将获取的差价、返点部分分赃给公司员工，对公司员工及外部人员的行为应如何定性，司法实践中存在较大的争议，有认定为公司员工、外部人员分别构成非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，有认为二者构成非法经营同类经营罪的共同犯罪，有认为二者构成贪污罪的共同犯罪，有认为二者构成非法经营同类经营罪、背信损害上市公司利益罪的共同犯罪，有认为二者构成职务侵占共同犯罪。通过本案的审理，此类行为定罪的关键在于行为人的主体身份、是否侵占公司财产以及侵占公司财产的主要手段。

一、被告人王某某不具有公职职务犯罪、非法经营同类营业罪及背信损害上市公司利益罪的主体资格

(一)被告人王某某并非国家工作人员

被告人王某某虽然系国有上市公司下属子公司某部门副经理，但其并非国

